



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
CAF 89556/2018/CA1 “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ EN –
Honorable Cámara de Senadores de la Nación y otro s/ amparo ley 16.986”

Buenos Aires, 4 de febrero de 2020.

VISTO:

El recurso de apelación deducido por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia a fs. 177/184 contra la sentencia de fs. 172/176, que rechazó la acción de amparo tendiente a acceder a los exámenes corregidos de los postulantes en el concurso de selección para la designación del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes; y

CONSIDERANDO:

1º) Que la **jueza de grado**, apartándose de lo dictaminado por el **fiscal de la instancia** (fs. 154/167), entendió que tales exámenes *no revestían carácter público*, en atención al anonimato asegurado por los arts. 3º, 8º y 9º del Reglamento de Procedimiento de Concurso Público de Antecedentes y Oposición para designar al Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, en tanto aquéllos sólo podían ser revisados por los mismos postulantes y sólo a ellos les correspondía —si así lo desean— darlos a conocer. En este sentido, precisó que sólo el llamado a concurso y la información relacionada con la convocatoria tenían carácter público, no así los datos suministrados por los postulantes con carácter de declaración jurada, los exámenes o cualquier otro parámetro de prueba o comparación que se haya realizado. Sobre dicha base, concluyó que tales documentos incluyen —en muchos casos— datos personales que hacen a la intimidad de los postulantes (fs. 172/176).

2º) Que la parte **recurrente** se agravió de la errónea interpretación que recibieron las normas involucradas en el pronunciamiento apelado, tales como la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (27.275 y 25.326), y los tratados internacionales. Señaló que todas ellas exigen el acceso a los documentos pretendidos y que no se verifican las excepciones invocadas por la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para denegar su divulgación, vinculados con la afectación de derechos de terceros y el carácter secreto de la información (art. 8º, inc. d y h de la ley 27.275). En este sentido, cuestionó la apreciación efectuada por la magistrada en relación con los hechos y la calificación de la información pretendida como privada o secreta. Finalmente, destacó que el interés público comprometido en el



conocimiento de la evaluación de los candidatos a un cargo de tal importancia es mucho mayor al hipotético daño que tal revelación podría ocasionar a estos últimos (fs. 177/184).

En oportunidad de contestar el **traslado del memorial**, la Cámara de Diputados de la Nación insistió en que la información pretendida se encuentra resguardada por el art. 5º, inc. 1º de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, en cuanto exige el consentimiento del postulante para su exhibición, en tanto destacó que la imparcialidad del proceso de selección se encuentra resguardado por la propia Comisión Bicameral, circunstancia que exime su divulgación en los términos del art. 8º, incs. d e i, de la ley 27.275 (fs. 201/205). La Cámara de Senadores de la Nación, por su lado, informó que, el 26 de junio de 2016, se aprobó la designación de la Defensora y sus adjuntos, razón por la que —según sostuvo— la cuestión habría devenido abstracta (fs. 201/205).

3º) Que el Fiscal General dictaminó en sentido favorable a la procedencia del recurso y propuso hacer lugar al amparo, con fundamento en la presunción de publicidad de la información y de los principios de transparencia y máxima divulgación. Sobre dicha base, entendió que la falta de autorización expresa para la publicación de las evaluaciones no puede ser interpretada en el sentido de restringir el acceso a la información producida en el marco de un concurso público convocado para un cargo de relevancia institucional. Tampoco entendió configuradas las excepciones fundadas en el compromiso de derechos de terceros por resultar información obtenida en carácter confidencial o en el secreto profesional (art. 8º, incs. d y h, ley 27.275), en la medida en que los postulantes, al participar del concurso público de oposición y antecedentes, consintieron que sus datos fuesen recabados y se sometieron al reglamento aludido, que dispone el oportuno levantamiento del anonimato (fs. 208/211 y vta).

4º) Que los fundamentos de la sentencia y el tenor de los agravios (y sus respuestas) delimitan la tarea revisora de esta alzada respecto de la aplicación las normas jurídicas vinculadas y la apreciación de los hechos involucrados a los efectos de determinar: (i) si la finalización del procedimiento de selección obsta a la subsistencia de caso o controversia e impiden un pronunciamiento del Tribunal; en caso negativo, (ii) si la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
CAF 89556/2018/CA1 “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ EN –
Honorable Cámara de Senadores de la Nación y otro s/ amparo ley 16.986”

información pretendida es *pública* y en tal caso se rige por el principio de máxima divulgación establecido en la ley 27.275 o, por el contrario, reviste el carácter de *dato personal o sensible* protegido por el principio de autodeterminación informativa previsto en la ley 25.326; (iii) en la primera hipótesis (dato personal), si se verifican las excepciones que habiliten su exhibición, sea con apoyo en el compromiso de derechos de terceros por resultar información obtenida en carácter confidencial, o en el secreto profesional (art. 8, incs. d y h, ley 27.275).

Se encuentra excluido de la jurisdicción del Tribunal tanto el examen de la declinatoria como de la legitimación activa, en la medida en que tales cuestiones que fueron rechazadas en la instancia, no fueron objeto de apelación por la parte demandada (art. 271, CPCCN). A todo evento, cabe recordar el carácter amplio que se ha atribuido a la legitimación para acceder a la información pública (Fallos: 335:2393; 337:256 y 1108; 342:208).

5º) Que la invocada finalización del procedimiento de selección por la efectiva designación de la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes y sus adjuntos no produjo en autos la extinción del objeto procesal, toda vez que aquella circunstancia no produjo la desaparición del presupuesto fáctico y jurídico que dio pie a la demanda, vinculado con el interés de acceder a los fundamentos que determinaron la elección de los candidatos más idóneos para ocupar aquellos cargos, en la medida en que una parte de aquel concepto jurídico indeterminado se integró con el examen escrito y su calificación, cuyo conocimiento se persiguen autos.

De modo que **subsiste el caso o la controversia**, en la medida en que la parte demandada mantiene su posición denegatoria de brindar la información y la accionante, su interés en obtenerla vinculado con el escrutinio del criterio de selección adoptado en la designación de los candidatos más idóneos (Fallos: 342:208).

6º) Que una interpretación que permita la coexistencia armónica de las disposiciones existentes en el ordenamiento nacional en materia de datos personales y de acceso a la información —de acuerdo a la redacción que le han dado los propios demandados—, lleva a sostener que la ley 25.326 no alcanza a aquellos supuestos relativos a información personal que forma



parte de la gestión pública, pues ello significaría desconocer, o cuanto menos obstaculizar, el pleno goce de un derecho humano reconocido tanto en nuestra Constitución Nacional como en los Tratados Internacionales que la República Argentina ha suscripto. En consecuencia, cabe concluir que el hecho de que la información requerida por la actora involucre datos de un tercero no aparece como una razón dirimente para incluirla, sin más, dentro del ámbito de aplicación de la ley 25.326 (Fallos: 339:827).

En este sentido, el art. 8º, inc. i, de la Ley de Acceso a la Información Pública dispone que los sujetos obligados sólo pueden exceptuarse de proveer la información que les sea requerida cuando la información que contenga datos personales no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales (consentimiento o cesión). Por su parte, esta última define como “datos personales” a la “información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables” y como “datos sensibles” a aquellos “datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual” (art. 2º). Se dispone también que el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento, pero que éste no es necesario cuando: “...b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal” (artículo 5º).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que una adecuada interpretación de ambos preceptos permite concluir que en tanto la información que se solicita a uno de los sujetos obligados no se refiera al origen racial y étnico de terceros, sus opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, su afiliación sindical o se trate de información referente a la salud o a la vida sexual, su divulgación no conculca el derecho a su intimidad ni se afecta su honor y, en consecuencia, no existen razones para que los sujetos obligados nieguen el acceso a ella (Fallos: 337:256, considerando 18).

En el caso, la información solicitada por el demandante —cuya denegatoria fue convalidada por la jueza de grado en la sentencia apelada—





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
CAF 89556/2018/CA1 “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ EN – Honorable Cámara de Senadores de la Nación y otro s/ amparo ley 16.986”

no reviste el carácter de **datos personales** de los postulantes, en la medida en que no se refiere a estos últimos, sino que constituyen producciones intelectuales elaboradas por aquéllos en respuesta a preguntas formuladas en el marco de un examen de oposición. No tienen nada de personal, salvo en lo que se refiere a su autoría. Por otra parte, no se trata de una discusión sobre la protección de tales producciones en los términos del régimen de la propiedad intelectual aprobado por la ley 11.723, sino que la demandada pretende atribuir a los exámenes escritos y su corrección un atributo ajeno a su condición y ello determinó la equivocada aplicación de un régimen previsto para otros supuestos.

Tampoco puede considerarse como **datos sensibles**, ya que los exámenes escritos no revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical o información referente a la salud o a la vida sexual (conf. definiciones del propio art. 2º, ley 25.326). En todo caso, tales producciones intelectuales permiten advertir la mayor o menor idoneidad para ocupar el cargo al que aspiran los candidatos, a tenor de la calificación que cada uno habría merecido. Esta información resulta de innegable interés público en tanto permite conocer aspectos relevantes del criterio utilizado para la calificación de los exámenes y, en consecuencia, para la determinación de los candidatos más idóneos para ocupar cargos de máxima relevancia institucional, y facilita a quien requiere la información ejercer el control sobre la regularidad de los actos de designación. En este punto, cabe destacar que la demandada no se opuso a publicar la calificación que obtuvo cada aspirante, sino la evaluación al que aquélla remite.

De modo que los exámenes rendidos en el marco de un concurso público de oposición y antecedentes no revisten el carácter de **dato personal o sensible** protegido por la ley 25.326, razón por la que su divulgación no constituye una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, y por tal motivo no resulta necesario el consentimiento de los postulantes (arts. 5º); ni tampoco permite la invocación de la excepción a su divulgación establecida por el art. 8º, inc i, de la ley 27.275.

7º) Que, descartado el carácter privado de la información pretendida, cabe recordar que la ley 27.275 establece la presunción de que toda la



información en poder del Estado resulta pública, razón por la que su acceso sólo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones previstas en esa norma, de acuerdo con las necesidades de la sociedad democrática y republicana, proporcionales al interés que las justifican. Asimismo, los límites al derecho de acceso a la información pública deben ser excepcionales, establecidos previamente conforme a lo estipulado en esa ley, y formulados en términos claros y precisos, quedando la responsabilidad de demostrar la validez de cualquier restricción al acceso a la información a cargo del sujeto al que se le requiere. Finalmente, la interpretación de las disposiciones de esta ley o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información debe ser efectuada, en caso de duda, siempre en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información (art. 1º, ley 27.275, en el mismo sentido, “Savoia”, Fallos 342:208).

Los sujetos obligados, carácter que reviste el Congreso de la Nación (art. 7º, inc. b, ley 27.275), sólo podrán exceptuarse de proveer la información cuando se configure alguno de los siguientes supuestos: “[...] *d) Información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial; i) Información protegida por el derecho profesional*” (art. 8º, ley 27.275).

Se advierte que el temperamento adoptado por la comisión parlamentaria no se funda en el secreto de la información, sino en la protección de los terceros participantes del concurso. Tan es así que la pretensión de la actora no fue denegada lisa y llanamente, sino que se condiciona su entrega al consentimiento expreso de estos últimos (esta Sala, CAF 22888/2018/CA1 “Asociación de Defensa de los Derechos del Consumidor de Seguros c/ EN – Superintendencia de Seguros de la Nación s/ amparo ley 16.986”, resol. del 28 de mayo de 2019).

En este sentido, no se advierte la necesidad de brindar a los postulantes de concursos públicos un resguardo de los exámenes, ya que quien pretende acceder a un cargo de ese mismo carácter no puede aspirar a que su examen permanezca en secreto, ni sentirse afectado porque se conozcan su calificación en las pruebas y, eventualmente, los fundamentos





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
CAF 89556/2018/CA1 “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ EN – Honorable Cámara de Senadores de la Nación y otro s/ amparo ley 16.986”

que determinaron su elección como el candidato más idóneo en el universo de aspirantes.

Es cierto que el derecho de toda persona a conocer el criterio de evaluación de quienes fueron considerados como candidatos más idóneos para ocupar los cargos públicos en cuestión supone el reconocimiento de un ámbito más limitado de la privacidad de los exámenes que rindieron. En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que *"en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han prestado voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la del debate público. Este umbral no solo se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza"* (caso "Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina", sentencia del 29 de noviembre de 2011, párrafo 47; en análogo sentido confr. Fallos: 331:1530; 332:2559 y 335:2150).

Por su parte, aquellos postulantes que no fueron elegidos y no revisten el carácter de funcionario público también encuentran restringida la privacidad de la actividad que despliegan en el ámbito del procedimiento de selección. Al igual que los oferentes en procedimientos competitivos de suministros, obras o servicios públicos, la información que incorporen a la licitación o al concurso se encuentra regida por el principio de transparencia y libre acceso (arts. 3º, incs. c, y d, 9º, 19 del decreto 1023/01 y art. 8º de la ley 25.152), circunstancia que torna inoponible su reserva (esta Sala, arg. causa 37166/2013 “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo y otro c/ EN – Mº Planificación Federal s/ amparo ley 16.986”, resol. del 13 de febrero de 2014). Máxime, cuando el procedimiento se encuentra concluido y no se advierte ningún motivo que justifique diferir tal divulgación.

Tal como lo señala con acierto el Ministerio Público Fiscal de ambas instancias, el reglamento del concurso estableció la reserva de la identidad de los postulantes con el objeto de garantizar la imparcialidad en la corrección de las evaluaciones, mas nada previó respecto de su difusión *con posterioridad* al entrecruzamiento con los códigos alfanuméricos otorgados a los concursantes. En efecto, el art. 9º del capítulo III del anexo



IV del reglamento de procedimiento para la designación en el cargo en cuestión establece:

“... una vez finalizada la corrección [de las evaluaciones] se suprimirá el anonimato y se publicará, en la página web de la Comisión, el listado de los postulantes aprobados”

Desde esta óptica, se advierte la falta de configuración de tales excepciones, toda vez que las razones expuestas por la demandada no tienen entidad suficiente para justificar la confidencialidad de la información ni el secreto profesional de la Comisión Bicameral.

8º) Que, finalmente, se impone señalar que 7º, de la ley 27.275, identifica en forma clara y precisa a los sujetos obligados a garantizar el acceso a la información pública. Sobre ellos pesa, exclusivamente, dicho deber. En consecuencia, frente a la denegación de un requerimiento, la pretensión judicial orientada a conocer determinada información debe dirigirse sólo contra aquél a quien el ordenamiento define como sujeto pasivo de la obligación, en el caso bajo análisis, la Comisión Bicameral del Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes. No corresponde, entonces, dar intervención en el marco de la presente causa a los postulantes que, en su condición de terceros, ninguna alegación podrían formular en un pleito en el que, en definitiva, se debate el derecho de una persona a acceder a información de interés público. Máxime cuando esos terceros, al momento de participar en un concurso público de oposición y antecedentes, conocían, o cuanto menos debieron conocer, el régimen de publicidad al que se encontraba sometido el procedimiento de selección (Fallos: 338:1258).

En mérito a todo lo expuesto, condicionar su divulgación al consentimiento previo de los postulantes configura una arbitrariedad manifiesta que debe ser reparada por la vía elegida por la accionante (esta Sala, causa 5.111/10, “Asociación Derechos Civiles c/ EN – SMC s/ amparo ley 16.986”, resol. del 2 de noviembre de 2010), razón por la que el Tribunal, de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General **RESUELVE**: admitir el recurso, revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda, condenando a la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a que, en el plazo de 10 días, permita el acceso





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
CAF 89556/2018/CA1 “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ EN – Honorable Cámara de Senadores de la Nación y otro s/ amparo ley 16.986”

a copia íntegra de todos los exámenes de los candidatos que rindieron la prueba escrita para el concurso de oposición y antecedentes, del 28 de setiembre de 2018, corregidos y con sus respectivas notas, identificando en cada caso a los postulantes autores de cada uno de ellos, con costas de ambas instancias a la parte demandada en su condición de vencida (art. 14 y 17, ley 16.986 y 279, CPCCN).

Regístrese, notifíquese —al Fiscal General en su despacho— y devuélvase.

MARCELO DANIEL

DUFFY

JORGE EDUARDO MORÁN

ROGELIO W. VINCENTI
(según su voto)

El señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti dijo:

1º) Que las circunstancias fácticas fueron adecuadamente reseñadas en los considerandos 1º a 5º, a cuyos términos me remito para evitar reiteraciones innecesarias.

2º) Que, en atención a la materia involucrada en la causa y a los planteos que se traen a conocimiento de esta alzada, conviene recordar que en distintos precedentes el Tribunal se ha encargado de resaltar la importancia del derecho de acceso a la información pública como una de las aplicaciones del principio de publicidad de los actos de gobierno, que si bien no está enumerado expresamente en la Ley Fundamental, ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como derecho de naturaleza social, que garantiza a toda persona — física o jurídica, pública o privada— el conocimiento y la participación en



todo cuanto se relaciona con los procesos políticos, gubernamentales y administrativos y se evidencia, en tanto enderezado a la obtención de información sobre los actos públicos (arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional), como inherente al sistema republicano y la publicidad de los actos de gobierno (esta Sala, “Fitz Patrick, Mariel c. EN s/ amparo ley 16.986”, sent. del 31/10/13, con cita de precedentes del Alto Tribunal [LL 2013-F, 340]).

En este mismo sentido y con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación destacó que el fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan, mediante el acceso a la información (Fallos: 335:2393).

Mas así como ha puesto énfasis en garantizar y desarrollar este derecho, también se encargó de resaltar que el derecho de acceso a la información, en tanto elemento constitutivo de la libertad de expresión protegido por normas constitucionales y convencionales, no es un derecho absoluto sino que puede estar sujeto a limitaciones, por lo que resulta admisible que el ordenamiento jurídico establezca ciertas restricciones, las que deben ser verdaderamente excepcionales, perseguir objetivos legítimos y ser necesarias para alcanzar la finalidad perseguida (Fallos: 338:1258), y aclaró que el secreto solo puede justificarse para proteger un interés igualmente público, de modo que la reserva solo resulta admisible para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública (Fallos: 339:827).

3º) Que el marco normativo vigente, constituido por la ley 27.275 y normas complementarias, contiene disposiciones específicas, tales como los principios de presunción de publicidad, transparencia y máxima divulgación (art. 1º de la ley) y otros de igual tenor que sirven para resolver casos en los que esté involucrado el acceso a la información pública.

El legislador también previó que los sujetos obligados sólo podrán exceptuarse de proveer la información cuando se configure alguno de los





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
CAF 89556/2018/CA1 “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ EN –
Honorable Cámara de Senadores de la Nación y otro s/ amparo ley 16.986”

supuestos que establece el art. 8° de la ley 27.275 y su reglamento, aprobado por decreto 206/17.

A su vez, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), por distintas resoluciones, aprobó los criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas en la aplicación de la ley 27.275.

En lo que ahora interesa, el criterio 1 de la resolución 48/18, destinado a determinar el interés público, señala que, a efectos de la ley 27.275, aquél se entenderá como: 1. Información que resulta relevante y beneficiosa para la sociedad en general (excluyendo el mero beneficio individual), constructiva del bien común; por ejemplo: información referente a la salud pública, medio ambiente, seguridad pública, a asuntos socioeconómicos y políticos y a la transparencia en la gestión pública; 2. Información que afecte intereses o derechos generales; 3. Información referida al proceso político, a la gestión pública y al diseño de los marcos institucionales que gobiernan a la sociedad; 4. Información sobre asuntos necesarios para ejercer el control político sobre las instituciones, para participar en la toma de decisiones públicas que puedan afectar a la sociedad, o para ejercer los derechos políticos; por ejemplo: hechos que refieran a la administración de fondos públicos, a la malversación de fondos (o enriquecimiento ilícito) o al incumplimiento en el ejercicio de funciones públicas; 5. Información bajo control del Estado relativa a su gestión; 6. Información atinente a personas que actúan en un ámbito público, como funcionarios públicos o políticos. No obstante esto, se deben respetar las legítimas expectativas de privacidad de las figuras públicas de acuerdo a su función.

4°) Que, también es del caso recordar que, en fecha reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a expedirse sobre el tema y señaló que el derecho de acceso a la información se rige por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones, pues el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar,



indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas (“Savoia”, Fallos: 342:208, énfasis agregado).

Y, al ampliar sobre las excepciones, indicó que *“la restricción al derecho de acceso a la información pública debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho”* (cons. 10).

5º) Que, por último, también es necesario señalar que, no obstante que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se circunscriben a los procesos concretos que son sometidos a su conocimiento, la autoridad institucional de sus precedentes, fundada en la condición de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, da lugar a que en oportunidad de fallar casos sustancialmente análogos sus conclusiones sean debidamente consideradas y consecuentemente seguidas tanto por la misma Corte como por los demás tribunales (Fallos: 315:2386; 332:1488; 341:570, entre muchos otros), así como que cuando de las modalidades del supuesto a fallarse no resulta de manera clara el error y la inconveniencia de las decisiones ya recaídas sobre la cuestión legal objeto del pleito, su solución debe buscarse en la doctrina de los referidos precedentes (Fallos: 337:47; 339:1077; 341:570).

6º) Que, sobre tales bases, corresponde examinar los planteos que se traen a conocimiento de esta alzada, empezando por determinar la vinculación entre la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales, en la medida en que tanto la Comisión Bicameral como la sentencia de primera instancia denegaron la solicitud de la asociación civil actora con fundamento en que la última de las leyes citadas impedía dar a conocer la información requerida.

Al respecto, cabe recordar que la ley 27.275 establece varios principios rectores en la materia. Entre ellos, el de *presunción de publicidad*, que consiste en que toda la información en poder del Estado se presume pública, salvo las excepciones previstas por esta ley, o el de *transparencia y máxima divulgación*, por el cual toda la información en poder, custodia o bajo control del sujeto obligado debe ser accesible para todas las personas.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
CAF 89556/2018/CA1 “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ EN – Honorable Cámara de Senadores de la Nación y otro s/ amparo ley 16.986”

Y aclara, expresamente, que el acceso a la información pública sólo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones previstas en esa ley, de acuerdo con las necesidades de la sociedad democrática y republicana, proporcionales al interés que las justifican (art. 1º de la ley 27.275).

En este sentido, el art. 8º, inc. i, de la ley dispone que los sujetos obligados sólo pueden exceptuarse de proveer la información que les sea requerida cuando la información que contenga datos personales no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de la ley 25.326 (consentimiento o cesión). Por su parte, esta última ley define como tales a la *“información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables”* y como *“datos sensibles”* a aquellos *“datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”* (art. 2º de la ley 25.326). Se dispone también que el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento, pero que ello no resulta necesario cuando: *“...b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal”* (art. 5º).

7º) Que una interpretación que permita la coexistencia armónica de las disposiciones existentes en el ordenamiento nacional en materia de datos personales y de acceso a la información, lleva a sostener que la ley 25.326 no alcanza a aquellos supuestos relativos a información personal que forma parte de la gestión pública, pues ello significaría desconocer, o cuanto menos obstaculizar, el pleno goce de un derecho humano reconocido tanto en nuestra Constitución Nacional como en los Tratados Internacionales que la República Argentina ha suscripto. En consecuencia, cabe concluir que el hecho de que la información requerida por la actora involucre datos de un tercero no aparece como una razón dirimente para incluirla dentro del ámbito de aplicación de la ley 25.326 (Fallos: 339:827).

En este sentido, La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que una adecuada interpretación de ambos preceptos permite concluir que en tanto la información que se solicita a uno de los sujetos obligados no se



refiera al origen racial y étnico de terceros, sus opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, su afiliación sindical o se trate de información referente a la salud o a la vida sexual, su divulgación no conculca el derecho a su intimidad ni se afecta su honor y, en consecuencia, no existen razones para que los sujetos obligados nieguen el acceso a ella (Fallos: 337:256, considerando 18).

En el caso, la información solicitada por la asociación civil actora (exámenes y sus correcciones) no reviste el carácter de datos personales de los postulantes, en la medida en que no se refiere a estos últimos, sino que constituye producciones intelectuales elaboradas por aquéllos en respuesta a preguntas formuladas en el marco de un examen de oposición. No tienen nada de personal, salvo en lo que se refiere a su autoría. Por otra parte, no se trata de una discusión sobre la protección de tales producciones en los términos del régimen de la propiedad intelectual aprobado por la ley 11.723, sino que la demandada pretende atribuir a los exámenes escritos y su corrección un atributo ajeno a su condición y ello determinó la equivocada aplicación de un régimen previsto para otros supuestos.

Tampoco puede considerarse datos sensibles, ya que los exámenes escritos no revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical o información referente a la salud o a la vida sexual (conf. definiciones del propio art. 2º de ley 25.326). En todo caso, tales producciones intelectuales permiten advertir la mayor o menor idoneidad para ocupar el cargo al que aspiran los candidatos, a tenor de la calificación que cada uno habría merecido.

Esta información resulta de innegable interés público, en tanto permite conocer aspectos relevantes del criterio utilizado para la calificación de los exámenes y, en consecuencia, para la determinación de los candidatos más idóneos para ocupar cargos de máxima relevancia institucional, al mismo tiempo que facilita a quien requiere la información ejercer el control sobre la regularidad de los actos de designación.

En este punto, cabe destacar que la demandada no se opuso a publicar la calificación que obtuvo cada aspirante, sino el examen al que aquélla remite.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
CAF 89556/2018/CA1 “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ EN – Honorable Cámara de Senadores de la Nación y otro s/ amparo ley 16.986”

De modo que los exámenes rendidos en el marco de un concurso público de oposición y antecedentes no revisten el carácter de dato personal o sensible protegido por la ley 25.326, razón por la que su divulgación no vulnera el derecho a la intimidad y al honor, y por tal motivo no resulta necesario el consentimiento de los postulantes (art. 5°); ni tampoco permite la invocación de la excepción a su divulgación establecida por el art. 8°, inc i, de la ley 27.275.

8°) Que, descartado el carácter privado de la información pretendida, cabe insistir en que la ley 27.275 establece la presunción de que toda la información en poder del Estado resulta pública y que su acceso sólo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones previstas en esa norma, de acuerdo con las necesidades de la sociedad democrática y republicana, proporcionales al interés que las justifican. Asimismo, los límites al derecho de acceso a la información pública deben ser excepcionales, establecidos previamente conforme a lo estipulado en esa ley, y formulados en términos claros y precisos, quedando la responsabilidad de demostrar la validez de cualquier restricción al acceso a la información a cargo del sujeto al que se le requiere la información. Finalmente, la interpretación de las disposiciones de esta ley o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información debe ser efectuada, en caso de duda, siempre en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información (art. 1° de la ley 27.275, en el mismo sentido, “Savoia”, Fallos 342:208).

Los sujetos obligados, carácter que reviste el Congreso de la Nación (art. 7°, inc. b, ley 27.275), sólo podrán exceptuarse de proveer la información cuando se configure alguno de los siguientes supuestos: “[...] d) *Información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial; i) Información protegida por el derecho profesional*” (art. 8°, ley 27.275).

Se advierte que el temperamento adoptado por la comisión parlamentaria no se funda en el secreto de la información, sino en la protección de los terceros participantes del concurso. Tan es así que la pretensión de la actora no fue denegada lisa y llanamente, sino que se condiciona su entrega al consentimiento expreso de estos últimos (esta Sala,



CAF 22888/2018/CA1 “Asociación de Defensa de los Derechos del Consumidor de Seguros c/ EN – Superintendencia de Seguros de la Nación s/ amparo ley 16.986”, resol. del 28 de mayo de 2019).

En este sentido, no se advierte la necesidad de brindar a los postulantes de concursos públicos un resguardo de los exámenes, ya que quien pretende acceder a un cargo público no puede aspirar a que su examen permanezca en secreto, ni sentirse afectado porque se conozca su calificación en las pruebas y, eventualmente, los fundamentos que determinaron su elección como el candidato más idóneo del universo de aspirantes.

Es cierto que el derecho de toda persona a conocer el criterio de evaluación de quienes fueron considerados como candidatos más idóneos para ocupar los cargos públicos en cuestión supone el reconocimiento de un ámbito más limitado de la privacidad de los exámenes que rindieron. En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que *“en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han prestado voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la del debate público. Este umbral no solo se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza”* (caso "Fontevicchia y D'Amico vs. Argentina", sentencia del 29 de noviembre de 2011, párrafo 47; en análogo sentido confr. Fallos: 331:1530; 332:2559 y 335:2150).

Por otra parte, aquellos postulantes que no fueron elegidos y no revisten el carácter de funcionarios públicos también encuentran restringida la privacidad de la actividad que despliegan en el ámbito del procedimiento de selección. Al igual que los oferentes en procedimientos competitivos de suministros, obras o servicios, la información que incorporen a la licitación o concurso se encuentra regida por el principio de transparencia y libre acceso (arts. 3º, incs. c, y d, 9º, 19 del decreto 1023/01 y art. 8º de la ley 25.152), circunstancia que torna inoponible su reserva (esta Sala, arg. causa 37166/2013 “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo y otro c/ EN – Mº Planificación Federal s/ amparo ley 16.986”, resol. del 13 de febrero de 2014). Máxime,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
CAF 89556/2018/CA1 “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ EN – Honorable Cámara de Senadores de la Nación y otro s/ amparo ley 16.986”

cuando el procedimiento se encuentra concluido y no se advierte ningún motivo que justifique diferir tal divulgación.

Tal como lo señala con acierto el Ministerio Público Fiscal de ambas instancias, el reglamento del concurso estableció la reserva de la identidad de los postulantes con el objeto de garantizar la imparcialidad en la corrección de las evaluaciones, más nada previó respecto de su difusión con posterioridad al entrecruzamiento con los códigos alfanuméricos otorgados a los concursantes. En efecto, el art. 9º del capítulo III del anexo IV del reglamento de procedimiento para la designación en el cargo en cuestión establece:

“... una vez finalizada la corrección [de las evaluaciones] se suprimirá el anonimato y se publicará, en la página web de la Comisión, el listado de los postulantes aprobados”

Desde esta óptica, se advierte la falta de configuración de tales excepciones, toda vez que las razones expuestas por la demandada no tienen entidad suficiente para justificar la confidencialidad de la información ni el secreto profesional de la Comisión Bicameral.

9º) Que, finalmente, se impone señalar que 7º de la ley 27.275 identifica en forma clara y precisa a los sujetos obligados a garantizar el acceso a la información pública. Sobre ellos pesa, exclusivamente, dicho deber. En consecuencia, frente a la denegación de un requerimiento, la pretensión judicial orientada a conocer determinada información debe dirigirse solo contra aquel a quien el ordenamiento define como sujeto pasivo de la obligación, en el caso bajo análisis, la Comisión Bicameral del Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes. No corresponde, entonces, dar intervención en el marco de la presente causa a los postulantes, que en su condición de terceros ninguna alegación podría formular en un pleito en el que, en definitiva, se debate el derecho de una persona a acceder a información de interés público. Máxime cuando esos terceros, al momento de participar en un concurso público de oposición y antecedentes, conocían, o cuanto menos debieron conocer, el régimen de publicidad al que se encontraba sometido el procedimiento de selección (Fallos: 338:1258).

En mérito a todo lo expuesto, condicionar su divulgación al consentimiento previo de los postulantes configura una arbitrariedad



manifiesta que debe ser reparada por la vía elegida por la accionante (esta Sala, causa 5.111/10, “Asociación Derechos Civiles c/ EN – SMC s/ amparo ley 16.986”, resol. del 2 de noviembre de 2010).

Por ello, de conformidad en lo pertinente con el dictamen del Fiscal General, me pronuncio por admitir el recurso de la actora y revocar la sentencia apelada. En consecuencia, cabe hacer lugar a la pretensión y ordenar a la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a que, en el plazo de 10 días, permita el acceso de copia íntegra de todos los exámenes de los candidatos que rindieron la prueba escrita para el concurso de oposición y antecedentes, del 28 de septiembre de 2018, corregidos y con sus respectivas notas, identificando en cada caso a los postulantes autores de cada uno de ellos, con costas de ambas instancias a la parte demandada en su condición de vencida (art. 14 y 17, ley 16.986 y 279, CPCCN). **ASÍ VOTO.**

ROGELIO W. VINCENTI

